

(二)商品关联程度

只有当相关公众认为被诉侵权标识与涉案注册商标存在相当程度的联系时，涉案注册商标才有被弱化的可能，故既要准确划定相关公众的范围，也要确定“相当程度联系”所需达到的高度。驰名商标淡化认定中的“相关公众”应与认定驰名商标的“相关公众”要件区分开来，认定驰名商标中的“相关公众”是知名度的影响范围，而驰名商标淡化认定中的“相关公众”则是造成误导的范围。由于驰名商标淡化保护是在其所使用的商品或者服务类别之外主张权利，故

而亦应以被诉商标所使用的商品或服务类别的相关公众作为判断的对象。因为只有以被诉商标所使用的商品或服务类别的相关公众作为判断主体，才能对被诉商标是否“误导公众”这一结果进行判断。具体到本案中，被诉侵权标识使用于油条等食品以及早餐餐饮服务上，理论上其相关公众系一般普通公众。但从日常经验上判断，早餐餐饮服务所提供的油条等食品通常是当日现做并现场提供售卖，其作为实体服务还受到经营场所区域的严格限制，故其相关消费者主要是该经营场所有限覆盖区域内的上班族、学生或邻近住户，且通常因通勤等需要对该餐饮服务的便捷性具有更高要求，而对其使用的商标标识的注意程度较低。

(三)“相当程度关联”的“误导公众”标准

驰名商标之所以应给予跨类保护，是因为驰名商标的影响已经超出了其原本注册或使用的商品或服务类别，因此在跨类保护时不仅要求驰名商标在其使用商品服务的相关公众领域内达到驰名的程度，还要求在主张跨类保护的商品服务领域相关公众中亦具备一定的知名度。但若驰名商标本

212 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

身的显著性有限、二者使用商品服务类别相差过大，或二者存在相关公众易于识别的因素，相关公众即使对二者之间的关系产生一般联想，也不足以建立起“相当程度的关

联”,从而导致误认。本案中即此种情形,被诉标识与权利商标分别使用在食品、餐饮服务以及计算机软件等完全不同的类别上,二者分属完全不同的市场,彼此不存在重合或关联关系,相关公众不易对二者之间的关系产生联想。因此,某油条公司等使用被诉标识不足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,并不会产生“误导公众”的效果,不存在削弱权利商标与计算机软件等商品(服务)之间的联系,从而弱化驰名商标的情形。

总而言之,无论是从保护勤勉、鼓励创新、维护公平的层面,还是从维护消费者合法权益的层面出发,对驰名商标进行特殊保护都是必要和正当的。但是,对于驰名商标的特殊保护,应当基于利益衡平原则合理划定保护界限,既要防止对自由表达、适度模仿的过度限制,更要避免对市场自由和公平竞争空间的随意挤压。

编写人:广州知识产权法院 韦晓云 林新宇

驰名商标与注册商标权利冲突的解决路径

——某儿童出版社诉××A公司等侵害

商标权及不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市高级人民法院(2023)沪民终406号民事判决书

2. 案由:侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某儿童出版社

被告(上诉人):××A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司

被告:某信息技术公司

【基本案情】

某儿童出版社系《十万个为什么》系列图书的出版者及相关权益享有者。《十万个为什么》自1961年首次出版以来共计出版六版,此外,还有其他十余种版本的系列图书,该系列图书多次获评国家级、省市级奖项及荣誉,被《解放日报》《人民日报》等多家媒体所大量报道。2017年6月、2020年8月,某儿童出版社在第16类书籍等商品上分别被核准注册了第17××619号“7+个为竹”、第36××859号“十万个为什么”商标(以下简称权利商标),并将上述商标使用于《十万个为什么》多版本书籍、部分杂志、科普短视频及少儿科普剧、动漫等。甲鞋业公司于2018年8月至2020年3月期间在第25类服装、鞋、帽等商品上陆续注册了第25××683号“十万个为什么”、第29××921号“[ooooowlrys”、第33××582号“重”、第39××355号“十万个沟什么”商标。2020年7月,其还在第35类广告、替他人推销等服务类别上注册了第41××888号“ooooowlwys”商标。甲鞋业公司曾出具多份商标授权书,将上述商标授权××A公司、乙鞋业公司使用。××A公司将“十万个为什么”作为企业名称及甲电商店铺、乙电商店铺、丙电商店铺名称,将“ ”标识用于其乙电商、丙电商店铺头像;在某平台以用户名“十万个为什么”发布科普短视频,并认证为“十万个为什么”官方账号;在丙电商店铺、甲电商店铺网页页面上突出使用“十万个沟什么”“+万个为什么,”标识。××A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司在乙电商店铺等多个平台的店铺内出售的童鞋商品上使用“foooooulenye”“言”标识。某儿童出版社主张“十万个为什么”应作为有一定影响的商品名称保护,两权利商标应被认定为驰名商标,前述三被告行为不仅构成不正当竞争,也构成对其注册商标专用权的侵害。某信息技术公司作为乙电商平台的经营者,为三被告商标侵权行为提供了帮助。

【案件焦点】

1. 权利商标是否能被认定为驰名商标；2. 被诉侵权行为是否构成商标侵权及不正当竞争。

【法院裁判要旨】

上海知识产权法院经审理认为：在权利商标被注册前，“十万个为什么”系列图书在少儿科普图书领域享有很高的知名度和美誉度，被相关公众广为知悉，已经具备了识别图书商品来源的属性特征，可以作为有一定影响的商品名称保护。××A公司使用“十万个为什么”作为其企业字号及多个平台的店铺名称，构成擅自使用某儿童出版社有一定影响的商品名称的不正当竞争行为。该被告在某平台上的相关宣传行为亦构成虚假宣传。被诉侵权商品为童鞋，与某儿童出版社商标核定使用的商品类别既不相同也不类似，故有必要对该商标是否驰名作出判定。某儿童出版社“首÷个自做”商标被注册前，已开始使用于《十万个为什么》杂志中，该商标主要部分是“十万个为什么”，故“十万个为什么”在科普图书领域所积累的高知名度自然会延续至该商标。该商标经过某儿童出版社持续使用及广泛宣传，已经具有很高的知名度和市场声誉，应被认定为驰名商标。三被告在童鞋上使用“f0c0oulutys”标识的行为，虽属于对其注册商标的使用，但系复制、摹仿或者翻译某儿童出版社驰名商标，具有攀附某儿童出版社驰名商标知名度的主观故意，已造成相关公众的混淆，构成对某儿童出版社注册商标专用权的侵害。某儿童出版社“一个当件么”商标的主要部分即为“莱万合为错么”，其注册日早于某儿童出版社“莱万个油件么”商标，“叶万个的借么”商标的注册日亦晚于被诉侵权行为开始实施的时间。且就某儿童出版社指控的被告与“十万个为什么”有关的使用行为，法院已通过有一定影响的商品名称予以保护。故本案中，并无必要对某儿童出版社“骨万个的错么”商标是否驰名作出认定，法院对某儿童出版社要求对该商标亦进行驰名商标认定的主张不予支持。鉴于涉案乙电商店铺商品已被禁售，法

院对某儿童出版社要求某信息技术公司停止侵权的诉请不再支持。

上海知识产权法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条，《中华人民共和国商标法》第十三条第一款及第三款、第十四条第一款及第四款、第五十七条第三项及第七项、第六十三条第一款及第三款，《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条第一项、第八条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第二项、第九条第二款、第十条，《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第五条第一款及第三款、第十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》第四条、第十二条第一款及第二款、第十七条、第二十三条、第二十五条之规定，判决如下：

一、x×A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司于本判决生效之日立即停止侵害某儿童出版社第17××619号注册商标专用权的行为；

二、被告x×A公司于本判决生效之日立即停止对某儿童出版社的不正当竞争行为并于本判决生效之日起三十日内立即停止使用其企业名称；

三、被告x×A公司就其实施的商标侵权及不正当竞争行为，被告甲鞋业公司、乙鞋业公司就其实施的商标侵权行为于本判决生效之日起三十日内在《中国知识产权报》非中缝版面刊登声明、消除影响(刊登声明的内容需经法院核准)。逾期不履行的，由法院在上述报纸刊登本案判决书内容，费用由被告××A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司承担；

四、被告x×A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司就其实施的商标侵权行为于本判决生效之日起十日内赔偿某儿童出版社经济损失人民币50万元；

五、被告××A公司就其实施的不正当竞争行为于本判决生效之日起十日内赔偿某儿童出版社经济损失人民币30万元；

六、被告××A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司于本判决生效之日起十日内赔偿某儿童出版社合理费用人民币108000元；

七、驳回某儿童出版社的其余诉讼请求。

x×A公司、甲鞋业公司、乙鞋业公司不服一审判决，提起上诉。

上海市高级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

当驰名商标与注册商标产生权利冲突时，首先需要对被告商标使用情况进行审查，若被告行为确属对其注册商标的使用范围，根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条的规定，若原告商标能作为驰名商标保护，而被告商标属于复制、摹仿或者翻译原告驰名商标的，原告有权要求禁止被告使用。因此，驰名商标案件中，法院有权就该类权利冲突问题进行审查。本案中，被诉侵权商品为童鞋，被告商标核定使用的商品类别包括鞋，故被告确实是在其注册商标核定范围内使用其商标。此时，原告、被告商标权产生了权利冲突。此类案件中，唯有原告商标满足驰名商标保护的条件下，其才有权要求禁止被告使用。审判实践中，在对原告商标驰名度的认定时，通常涉及对“认驰”必要性和“认驰”时间点的把握。

一、“认驰”必要性的把握

司法认定驰名商标应坚持按需认定、被动认定、个案认定、事实认定原则^①。按需认定意味着在案件审理确有必要的情况下，法院才能够并且也应当在个案中认定驰名商标。当权利人请求认定多枚商标驰名的情况下，可以根据案件处理需要，在确保权利人获得充分救济的前提下，认定其中一枚或部分商标驰名。如当被请求认定驰名的商标可以被另一个商标完全包含在内时，仅需要认定将其完全包含在内的商标为驰名商标，被包含的商标可以通过属于驰名商标的主要部分进行延伸保护，而并不必将其认定为驰名商标；多个被请求认定为驰名商标的商标注册时间不同且商标主要部分存在重合的，应认定注册时间更早的商标为驰名商标，其可以延伸保护到注册时间更晚的商标，因此注册

①袁春晓：《商标法通识》，知识产权出版社2020年版，第189页。

时间较晚且是其他商标主要部分的商标没有“认驰”的必要，仅需要通过认定注册时间在先的商标即可受到延伸保护。此外，若与涉案商标有关的被控侵权行为可以通过其他法律规定予以救济的，亦无需将其认定为驰名商标。

本案中，某儿童出版社请求将“+5个监什么”“十万个为什么”两枚商标认定为驰名商标，其中，“叶万个为什么”属于“+5个什2”商标的主要部分，且其注册日较晚，与其有关的主要被控侵权行为是××A公司对其企业及店铺名称的使用，而该使用行为法院已通过有一定影响的商品名称予以保护，因此并无必要对“叶万个为什么”商标是否驰名作出认定。 “ 十万个为什么”商标核定使用类别为第16类书籍，而被诉侵权行为所涉商标核定类别为第25类童鞋，两者既不相同也不类似，故确有必要对“7+石个熟色”商标是否构成驰名商标进行认定。

二、“认驰”时间点的把握

为了维护商标注册制度的稳定性，驰名商标与注册商标权利冲突案件中，在对原告商标驰名度进行审查时，还需要注意对“认驰”时间点的把握。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，法院在对该类案件进行审查时需要注意的除外情形之一为被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。即需审查被告提出商标注册申请时有无主观故意的问题，审查在被告提出注册申请时，原告的商标是否已驰名。若已驰名，应当推定被告明知原告商标，被告申请注册行为具有攀附原告商标的主观故意，构成对原告驰名商标的侵害。但若在该节点时原告商标尚未达到驰名程度，即便在这之后，经过原告的经营，其商标已经具备相当高的知名度，在诉讼时可以作为驰名商标考虑，但鉴于在被告申请注册时其尚未驰名，则不能以此作为禁止被告使用其注册商标的理由，相应诉请不应得到支持。

本案在对“认驰”时间点进行审查时，遇到审理难点，即从原告商标核准注册至被告商标申请注册的时间间隔非常短，仅7个多月，根据原告对涉案商标的使用情况，能否认定在被告商标申请注册前，原告商标已被认定为驰名

商标?诚然,权利商标注册时间的长短确实是审判驰名商标案件中通常需要考虑的因素。但本案特殊性在于,涉案《十万个为什么》系列图书早在1961年就已首次出版,截至2013年,历时近五十年,已经先后出版六版,累计发行量超过1亿册。其第六版的发行量居当时中国科普读物发行量之首。自《十万个为什么》图书首次出版以来,该系列图书获奖无数,所获奖项中包括“国家级科学技术进步奖”等高规格的奖项,在业界得到很高的评价。“十万个为什么”在少儿科普图书领域已经具有非常显著的商标识别度及很高的知名度。鉴于



“十万个为什么”商标主要部分是“十万个为什么”,故“十万个为什么”在科普图书领域所积累的高知名度自然会延续至该商标。该商标被注册后,经过与

《十万个为什么》系列图书及周边的持续紧密使用和广泛宣传,“5个做什么”商标的知名度亦得到进一步提升。因此,原告提供的证据已充分证明,在被告

商标申请注册前,“7+5国件么”商标已经具有很高的知名度和市场声誉,能够作为驰名商标保护。且经过原告持续使用及广泛宣传,该商标的知名度持续至今。被告行为已构成对原告驰名商标注册商标专用权的侵害。

编写人:上海知识产权法院 杜灵燕

“店招”攀附注册商标构成商标性使用

——佛山市凯某原创建筑装饰工程设计有限公司诉
南平市凯某装饰工程有限公司侵害商标权及
不正当竞争案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省南平市中级人民法院(2023)闽07民终434号民事判决书

2. 案由：侵害商标权及不正当竞争纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):佛山市凯某原创建筑装饰工程设计有限公司

被告(上诉人):南平市凯某装饰工程有限公司

【基本案情】

香港凯某集团是第2××3号“凯某”注册商标权利人。“凯某”商标于2018年3月21日核准注册,核定使用服务为第42类“包装设计、室内装饰设计”等,有效期至2028年3月20日。佛山市凯某原创建筑装饰工程设计有限公司(以下简称佛山凯某公司)成立于2015年12月16日,经营范围包括建筑装饰业、工程勘察设计。佛山凯某公司经香港凯某集团授权获得前述商标的独占许可使用权,并有权就任何侵害案涉商标专用权行为提起侵权诉讼。2020年5月12日,南平市凯某装饰工程有限公司(以下简称南平凯某公司)经登记注册为有限责任公司,经营范围为装饰装修工程设计、施工。

佛山凯某公司经委托公证机关调查发现,南平凯某公司未经许可擅自在其

店招、前台、图纸等位置使用“凯某”等商标标识；商铺前台接待人员潘某及设计师廖某在聊天过程中均提到案涉商铺系香港品牌，系全国连锁公司，廖某陈述其丈夫与香港凯某集团老板是同乡。佛山凯某公司认为，南平凯某公司的行为属于在相同/类似服务上使用与第2××3号“凯某”注册商标相同/近似商标的行为，已侵犯佛山凯某公司注册商标专用权，同时还违反《中华人民共和国反不正当竞争法》，具有混淆和引人误解的商业宣传行为，因此诉请法院判令南平凯某公司立即停止侵害佛山凯某公司第2××3号“凯某”注册商标专用权的行为、变更工商名称，并赔偿经济损失及维权合理费用共计120000元，登报赔礼道歉等。

【案件焦点】

南平凯某公司在其“店招”上使用“凯某”字样是否构成商标性使用。

【法院裁判要旨】

福建省武夷山市人民法院经审理认为：香港凯某集团系第2××3号“凯某”注册商标专用权人，该商标尚属保护期限内，其商标专用权应受法律保护。佛山凯某公司获香港凯某集团授权独占许可使用该商标，其可以原告身份主张该商标侵权的相关权利。本案中，南平凯某公司的企业字号中使用了他人注册商标“凯某”，虽然后者为繁体字，但并不影响公众将“凯某”与“凯某”作出同一性识别。当然，南平凯某公司的企业字号也是经过工商部门依法登记注册的，若未刻意误导公众，该企业字号本身并不当然构成侵权。但南平凯某公司在其店招、店内墙面上突出“凯某装饰”“凯某整装”字样，且南平凯某公司与香港凯某集团、佛山凯某公司的经营范围类似，均以室内装修设计为主营业务；在开展业务营销宣传时，南平凯某公司也有向客户表明其为“香港品牌”的宣传行为。因此南平凯某公司的上述行为属于突出性使用他人注册商标，构成《中华人民共和国商标法》意义上的“商标性使用”，侵犯了佛山凯某公司的商标专用权，应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。但如前分析，南平凯某公司的行为构成“商标性使用”侵权，而非不正当竞争行为，其正当使用企

业字号的权利仍应受到保护，不应承担“变更工商名称”的法律后果。

福建省武夷山市人民法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条，第五十七条，第六十三条第一款、第二款、第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，判决如下：

一、南平凯某公司立即停止侵害佛山凯某公司第2××3号“凯某”注册商标的行为；

二、南平凯某公司应于本判决生效之日起十日内赔偿佛山凯某公司经济损失及维权合理费用合计人民币20000元；

三、驳回佛山凯某公司的其他诉讼请求。

判决作出后，双方均提起上诉，福建省南平市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。从这一规定不难看出，商标的基本特征在于识别商品或者服务来源，商标性使用的目的是引导消费者识别商品或服务来源，从而购买其认可的商品，帮助商品提供者与消费者在市场上建立起重要的联系。因此，在审理商标侵权案件中，审查被告的行为是否构成“商标性使用”至关重要。

司法实践中，是否构成“商标性使用”，应综合考量以下三个方面因素：一是行为人在主观上是否善意；二是被诉标志的使用方式是否正当；三是使用被诉标志的后果是否会对相关公众造成混淆和误认。

其一，使用目的是否具有善意。商标法上的善意、恶意是从有无竞争的角度加以判断的。所谓善意，就是要么不知他人商标已注册，要么虽然知道注册，但未以恶意方式使用。恶意则是指虽知情却抱着不正当竞争目的使用。对此可

以参考注册商标的显著性、知名度、使用行为发生的时间等进行判断。本案中，商标所有权人香港凯某集团在室内装饰行业具有一定知名度，南平凯某公司与佛山凯某公司处于同一行业，且无正当理由使用与注册商标相同的标志，同时在招揽顾客时也特意表明其为“香港品牌”，容易让消费者产生南平凯某公司与香港凯某集团间存在联系，应认定其主观上有攀附和“搭便车”之嫌。

其二，使用方式是否具有正当性。主要考量被诉使用方式是否具有必要性和合理性：“必要性”通常要求使用者限于为说明商品而不可避免地使用商标中的标志，即若不使用该标志，将难以描述相关商品；“合理性”则考量行为人在使用他人商标标志时，是否附加了相应的说明性文字，标示了自己的商标或是否符合通常的行业惯例等。本案中，“凯某”实际上是姓氏商标，通过香港凯某集团、佛山凯某公司的使用而具有“第二层含义”。南平凯某公司与“凯某”这一姓氏本身没有任何联系点，也无法说明以“凯某”作为商号及店招的理由，却在其店招、店内墙面上突出了“凯某装饰”“凯某整装”等字样，虽然“凯某”商标为繁体字，但并不影响公众将“凯某”与“凯某”作出同一性识别，不能认为南平凯某公司的使用具有必要性和合理性，因此应当认定为商标性使用。

其三，使用后果是否会造成相关公众混淆和误认。“混淆可能性”是商标侵权案件的试金石。虽然南平凯某公司已依法将“凯某”登记为工商字号，但因“凯某”字样已被注册为商标，南平凯某公司在使用“凯某”字样进行广告宣传等行为时，应特别注意不能对相关公众造成混淆和误认。需要注意的是，注册商标和企业字号在市场经济活动中，扮演着相似的法律角色，二者都是为了将特定生产经营者所提供的商品和服务与其他经营者相区分，使相关公众可以有效地对特定商品或服务的提供者进行识别，从而起到引导消费选择和提供质量保证的作用。《企业名称登记管理规定实施办法》第三十四条规定，企业认为其他企业名称侵犯本企业名称合法权益的，可以向人民法院起诉或者请求为涉嫌侵权企业办理登记的企业登记机关处理。从上述规定可以看出，市场监管部门在审核相关主体的注册名称时，并不对工商主体字号名称是否侵害他人权利进行实质性审核，其核准注册的工商主体字号名称并不当然排除侵害他人

权利的可能性，即当工商主体字号与他人注册商标相同时，不能成为其在店招门头中使用注册商标显著性文字的理由，这种突出使用的行为仍然构成对他人注册商标权的侵害。本案中，南平凯某公司在店招中使用的虽然是其工商字号中的字样，但因该字样为他人注册商标，其突出使用行为、攀附宣介行为结合，容易导致相关公众的混淆与误认，因此构成商标侵权。

编写人：福建省武夷山市人民法院 余崇斌 张慧云

(三) 专利权权属、侵权纠纷

37

合理平衡先用权人与专利权人之间利益关系

——崔某诉拜泉县某农机有限公司侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院(2023)黑02民初46号民事判决书

2. 案由：侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

原告：崔某

被告：拜泉县某农机有限公司

【基本案情】

崔某于2019年10月25日向国家知识产权局申请“水箱(防高温)”的外观设计专利，该专利授权公告之日为2020年5月5日，专利号为：

ZL20193××1.7, 专利仍在保护期内。专利简要说明记载: 该外观设计产品的用途为农用水箱; 设计要点在于形状; 最能表明设计要点的图片或照片为使用状态图。2023年5月, 崔某在拜泉县某农机有限公司经营场所发现其销售与案涉专利权产品外观相似商品, 认为侵犯了崔某的外观设计专利使用权。拜泉县某农机有限公司称, 该种水箱为大型农用车用水箱, 其公司的李某曾经经营修理部多年, 早在崔某申请案涉专利前已生产该类型加工水箱, 因此该外观设计并非崔某发明, 只是被其先注册专利。

【案件焦点】

1. 涉诉侵权产品是否落入崔某涉案外观设计专利权的保护范围; 2. 拜泉县某农机有限公司主张的先用抗辩权能否成立。

【法院裁判要旨】

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院经审理认为: 拜泉县某农机有限公司享有案涉专利先用权, 侵权产品落入案涉专利权的保护范围, 是在原有范围内的继续制造、使用, 因此驳回崔某的诉讼请求。

一、涉诉侵权产品是否落入崔某涉案外观设计专利权的保护范围

崔某系案涉专利号为ZL20193××1.7、名称为“水箱(防高温)”的外观设计专利的所有权人, 该专利合法有效。任何单位或者个人未经专利权人许可, 不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售其外观设计专利产品, 否则应承担相应法律责任。根据《中华人民共和国专利法》第六十四条第二款的规定, 外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准, 简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条规定, 在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上, 采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的, 人民法院应当认定被诉侵权设计落入《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。第十条规定, 人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力, 判断外

观设计是否相同或者近似。本案中，涉诉侵权产品与案涉专利均系农机车用水箱，属于相同种类，经比对，两者外观基本相同，无明显差异，因涉诉侵权产品与案涉专利整体视觉效果上无实质性差异，故认定涉诉侵权产品落入案涉专利权的保护范围。

二、拜泉县某农机有限公司主张的先用抗辩权能否成立

根据《中华人民共和国专利法》第七十五条之规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权……（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的……”该公司于2016年4月6日注册，2019年3月23日通过某短视频平台发布涉诉侵权产品的视频，而案涉外观设计专利于2019年10月25日申请，通过比对时间可以认定该公司在案涉专利申请日前已制造相同产品，享有案涉专利先用权，该公司在原有范围内的继续制造、使用的行为，并未超过《中华人民共和国专利法》规定的“原有范围”。

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院依据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十四条、第七十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

驳回崔某的诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

先用权是指专利申请前，已经有人制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，则在申请人的专利获批后，上述人员可在原有范围内继续制造或者使用的权利。本案即合理平衡了先用权人与专利权人之间的利益关系，允许先使用人在原使用范围内继续制造、使用农机产品。

在人民法院确定先用抗辩权的审查方式时，应以专利权利要求为参照。时间上，先用权人的制造产品或者使用方法或与之相关的准备工作必须发生在专利申请日前；客观行为上，先用权人已经在进行制造产品、使用方法或已经作

好制造产品、使用方法的必要准备；权利行使条件上，先用权人在专利权人获得专利权后可以在原范围内继续制造和使用。本案中，通过比较涉诉侵权产品与涉案专利判断外观设计是否相同或者近似，以确定涉诉侵权产品落入案涉专利权的保护范围为前提，再进行先用抗辩权的确定，充分体现了法院在审理外观设计专利权类案时的价值选择。

一方面体现了对创造性劳动的尊重，在一些领域，如农机设计，会出现专利权人并非最先发明创造的人，先用权人缺乏知识产权保护意识，但他们的发明创造往往是在实践中千锤百炼经过检验而产生的，为社会技术创新、节约人力成本等作出了贡献，因此理应对他们的创造性劳动进行尊重与法律保护；另一方面体现了对公平原则的维护，《中华人民共和国专利法》采用先申请制，通过专利权的设立保护优先申请专利的人，但在实践中也会出现最先做出或使用发明专利创造的主体并不是最先提出专利权申请人，因此《中华人民共和国专利法》通过设立先用权抗辩制度用以平衡，同时防止滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断、恶意竞争的行为。本案充分体现了保护知识产权就是保护创新，通过司法审判保护农机领域的发明创造，守护创新的土壤，既是对发明创造的充分尊重，也是鼓励更多在农机领域的实践者与发明者加入保护自身创造性劳动的行列中，为推动社会经济高质量发展提供有力保障。

编写人：黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 刘捷

使用侵权外包装对其他产品进行包装的行为性质认定

——陆某诉某贸易公司等侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区高级人民法院(2023)桂民终242号民事判决书

2. 案由：侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陆某

被告(上诉人):某贸易公司、韦某

被告:某食品公司

【基本案情】

陆某是名称为“包装袋”、专利号为“ZL2020xxx×1307.4”的外观设计专利权人。专利简要说明载明该专利产品的用途为包装产品,设计要点在于形状与图案的结合。陆某向法院提交了证人蒙某在市场上购买的被诉侵权蛋黄酥产品,该产品外包装上注明生产厂家为某食品公司。陆某以某食品公司生产、销售侵权产品为由诉至法院。后因诉讼中某食品公司提交了其与某贸易公司之间的《代工协议》作为证据,陆某申请追加某贸易公司及其法定代表人韦某为本案被告,认为某贸易公司与某食品公司共同实施了制造、销售侵权产品的行为,并变更诉讼请求为:(1)判令某食品公司赔偿陆某经济损失及维权合理开支合计274931.25元;(2)判令某贸易公司、韦某对第一项诉讼请求承担连带责任。

【案件焦点】

某食品公司、某贸易公司使用侵权外包装来包装蛋黄酥食品的行为是否侵害了涉案外包装专利权。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：制造外观设计专利产品是指，专利权人的授权图片或者照片中的外观设计产品被实现。本案中，涉案外观设计专利产品为包装袋。根据查明事实，某食品公司仅是完成制作蛋黄酥后使用某贸易公司提供的包装袋加工成蛋黄酥产品成品，并交付某贸易公司，没有证据证明某食品公司制造了被诉侵权包装袋，某食品公司对其使用的被诉侵权包装袋也提供了送货单等证据证明其来源。被诉侵权包装袋上标识生产厂家为某食品公司，在一般消费者看来指向的是蛋黄酥产品的生产厂家为某食品公司，而非包装袋的生产厂家，该标识行为不应认定为专利法意义上的制造行为。陆某亦未提交证据证明某贸易公司存在制造被诉侵权包装袋的行为。故某食品公司、某贸易公司不存在制造侵权外包装产品的行为。

某贸易公司委托某食品公司生产涉案蛋黄酥产品并进行销售，其销售的蛋黄酥产品所使用的被诉侵权包装袋落入了涉案专利权的保护范围，故某贸易公司存在销售侵害涉案专利权的产品的行为，侵害了陆某享有的涉案专利权。某食品公司根据某贸易公司的委托加工完成后将成品交付某贸易公司，不构成销售，且没有证据证明某食品公司对某贸易公司销售蛋黄酥存在共同意思联络，故法院对陆某主张某食品公司存在销售侵权不予支持。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条第一款第八项，《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第六十四条第二款、第七十一条第一款至第三款，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、某贸易公司于本判决生效之日起十日内赔偿陆某经济损失及维权合理

开支共计50000元；

二、被告韦某对被告某贸易公司的上述第一项债务承担连带责任；

三、驳回原告陆某的其他诉讼请求。

某贸易公司、韦某不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区高级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

未经许可将(不侵权的)零配件组装成侵权专利产品的行为属于专利法意义上的制造行为。但在外包装外观设计专利侵权案件中，组装(包装)的行为性质认定具有一定特殊性。这是因为，外包装专利的专利产品和侵权产品都仅是外包装本身，但除了个别专门生产、销售外包装的商家外，大部分的外包装产品都是与其他产品结合形成成品后才进入终端市场，外包装属于整体成品中的“侵权零配件”。此时，无法直接适用前述的组装行为认定规则，而是应该参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十二条的规定，认定仅有将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并同时进行销售的行为，才属于侵权销售行为。

首先，从《解释》第十二条的规定看，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件的组装行为，不应构成制造行为，仅在同时存在后续销售行为的情况下，才会一并被认定为侵权销售行为。从行为本质上看，将外包装作为零部件组装(包装)其他产品的行为，显然不属于制造外包装的行为，而专利法中亦未对“使用”外观设计专利的行为作出规制，因此，该行为属于对外包装专利的使用行为，在未进行后续销售的情况下，仅组装(包装)行为不应认定为侵权。

其次，该条款中的后续“销售”行为应当作狭义理解，仅指通过独特的富有美感的外观设计获得利润的行为，不包括通过组装等其他加工工作获得利润的行为。市场分工日益细化，每个成品商品的背后通常都包含数个加工环节，而在侵权认定时，应当准确区分不同环节的行为及盈利实质，防

止对权利的过度保护。在外包装外观设计专利案件中，权利人取证购买的侵权成品背后，通

常会包含以下生产环节和主体：外包装生产、销售商(主动销售、受托定制)→外包装购买方(单纯购买、给图定制)→内装产品生产商、销售商→组装加工方(将外包装、内装产品等打包、组装、封袋)→成品销售商(将成品对外销售)。前述主体有可能重合或主体之间存在故意、共同侵权的情形；但无论具体的行为主体是一个还是多个，从行为的角度看，该链条中仅有第一个及最后一个行为应当被认定为侵权销售行为。其中，第一个行为，属于单纯的生产、销售外包装专利的行为，不涉及组装、成品环节，可以直接适用一般专利侵权对生产、销售行为的判断方法进行侵权认定；而最后一个行为，则是面向成品消费者的销售行为，该行为属于《解释》第十二条中的将外包装作为零部件制造另一产品“并销售”的行为。而除此之外，其他生产环节中，即使行为主体使用了该外包装进行加工，但该行为并非通过销售外包装盈利，而仅是提供劳务行为获取相应对价，此类中间行为均不应认定为对侵权外包装的销售行为。

最后，对于前述各个生产环节的查实，应由被告进行举证。成品产品包装上如明确载明了外包装生产者及包装内产品的生产者，则可以以此作为认定侵权外包装生产者的初步证据；如该包装上仅注明一个生产者，此时通常也可以推定该生产者应为整个成品的生产者，亦为产品各部件的制造者。若被告提出抗辩，则应由其来举示外包装、包装内产品及成品的生产、销售过程相关证据。

本案中，法院根据某食品公司的举证查明，某食品公司虽为侵权蛋黄酥产品外包装上注明的唯一生产商，但其已提交《代工协议》证明其受某贸易公司委托生产蛋黄酥食品，并将该食品装入某贸易公司提供的外包装中形成成品交付该贸易公司，故法院认为某食品公司根据《代工协议》获取生产蛋黄酥及组装工作的相应对价，不属于通过销售“外包装”或“外包装+产品”获取利益，故某食品公司的行为属于生产环节中的“组装加工方”，不应认定为《解释》第十二条规定的销售侵权行为；而根据在案证据，某贸易公司提供的外包装亦是从案外人公司处购得，虽然某贸易公司在本案中未以其与案外人公司之间的关系提出合法来源抗辩，但亦不宜认定某贸易公司存在生产外包装的行为，某

贸易公司仅为“外包装购买方”和“成品销售商”,因此,法院仅认定某贸易公司向市场销售使用了侵权外包装的蛋黄酥成品的行为,符合《解释》第十二条规定的构成要件,属于销售侵权。

在市场分工日益细化的大背景下,应准确把握知识产权保护的边界,更注重对零部件生产、销售各环节行为性质、行为特点的查实,区分整体产品中不同部分所享有的权利及其保护范围;本案正确认定了外包装专利侵权案件中各行为人的责任,合理分配举证责任,准确区分产品整体制造者和零部件制造者,对类案有一定的指导意义,通过准确的法律适用,为新质生产力发展提供了公平、优质的司法保护。

编写人:广西壮族自治区南宁市中级人民法院 韦丛君

单纯增产不视为先用权抗辩中的超范围使用在先技术

——安徽某材料科技股份有限公司诉江西某矿机股份有限公司

侵害实用新型专利权、侵害外观设计专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2023)最高法知民终1106号民事判决书

2. 案由:侵害实用新型专利权、侵害外观设计专利权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):安徽某材料科技股份有限公司

被告(被上诉人):江西某矿机股份有限公司

【基本案情】

涉案外观设计专利系名称为“半自磨机复合衬板(二)”、专利号为ZL20173052xxxx; 授权公告日为2018年4月10日; 涉案实用新型专利系名称为“用于自磨机和半自磨机的橡胶金属复合格子板”、专利号为ZL20202226××××; 授权公告日为2021年8月10日; 两专利的专利权人为安徽某材料科技股份有限公司。

2016年1月11日, 江西某矿机股份有限公司与案外人云南某股份有限公司签订半自磨机筒体复合衬板试用事宜的试用协议。2016年11月18日, 双方就半自磨机筒体复合衬板采购事宜签订供需合同。庭前会议上, 江西某矿机股份有限公司工作人员远程登录该公司CA×A PLM协同管理系统, 展示了筒体衬板(创建时间为2016年6月29日)的技术图纸。该设计用于大型半自磨机, 其整体近似薄壁扁圆筒形, 由多个近似长方形的单元沿产品周向紧密排列组合而成, 产品内周侧有向内凸起的近似梯形齿状结构(提升条)。2019年6月18日, 江西某矿机股份有限公司与案外人云南某锌铟股份有限公司签订半自磨机橡胶复合衬板(含外圈顽石窗即复合格子板)的供货合同。庭前会议上, 江西某矿机股份有限公司工作人员远程登录该公司CA×A PLM协同管理系统, 展示顽石窗(创建时间为2019年6月21日)的技术图纸。顽石窗所实施的技术方案为, 包括橡胶主体和耐磨钢板; 耐磨钢板内嵌于橡胶主体的外壁, 橡胶主体安装在磨机内的支撑结构上, 耐磨钢板开设有若干长条形的格子孔, 橡胶主体开设与格子孔一一对应的通孔。

【案件焦点】

1. 被诉筒体衬板是否落入涉案外观设计专利的保护范围, 被诉复合格子板是否落入涉案实用新型专利的保护范围; 2. 江西某矿机股份有限公司提出的先用权抗辩是否成立。

【法院裁判要旨】

江西省景德镇市中级人民法院经审理认为: 将涉案专利证书所载的立体图、

设计要点及《检索报告》与被告产品进行比对，二者整体视觉效果无实质性差异，属近似的外观设计，被告筒体衬板落入涉案外观设计专利权的保护范围。本案中，被告复合格子板照片已显示耐磨钢板、格子孔等技术特征，符合涉案实用新型专利权利要求1的技术特征。考虑到被告复合格子板系案外人正在使用的大型机械的组成部分，导致原告举证存在困难，被告复合格子板的技术特征与涉案实用新型专利权利要求1中所包含的技术特征相同存在高度可能性，故认定被告复合格子板落入涉案实用新型专利权的保护范围。

江西某矿机股份有限公司提出先用权抗辩。将被告在涉案实用新型专利申请日之前生产销售的顽石窗产品的技术特征与涉案实用新型专利权利要求1的技术特征进行比对，二者技术特征相同，系相同产品。将被告在涉案外观设计专利申请日之前生产销售的筒体复合衬板产品与涉案外观设计专利进行比对，二者产品用途相同，属于相同种类的产品，在整体视觉效果上并无实质性差异，系相同产品。

综上，法院认定江西某矿机股份有限公司在涉案专利申请日前已经制造并销售了相同产品，且安徽某材料科技股份有限公司无证据证明江西某矿机股份有限公司超出原有范围制造销售，江西某矿机股份有限公司的先用权抗辩成立。故江西某矿机股份有限公司制造销售被告复合格子板、被告筒体衬板的行为不视为侵犯专利权。

江西省景德镇市中级人民法院依照《中华人民共和国专利法》第六十四条、第七十五条第二项，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条、第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

驳回安徽某材料科技股份有限公司的全部诉讼请求。

安徽某材料科技股份有限公司不服一审判决，提起上诉。

最高人民法院经审理认为：在案证据不足以证明江西某矿机股份有限公司超出原有范围继续制造被告侵权产品。已有生产规模并不绝对等同于生产产能，如果生产设备未增加，即使产能有所增加，只要在已有设备可能达到的最大产

能范围内，一般也属于原有范围。

最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

专利权是一种合法的对世性、垄断性权利。在某些特定情形下，当专利权的行使可能与社会公众或其中个体的合法权益发生冲突时，一般会对专利权的保护进行一定限制进而合理平衡各方利益，如将在先使用人的特定行为视为不侵权，并允许其在被控侵权时提出抗辩以便得以继续使用。不承担专利侵权责任 的在先使用例外，在学理上也常被简称为“先用权抗辩”。

一、规则与实践：解析有效行使先用权抗辩的法定条件

先用权抗辩是基于公平原则对专利保护先申请制度作出的补救措施。在公共政策上，先用权抗辩的适用需要考虑促进产业发展的目的，先用权抗辩的目的是平衡专利权人和先用权人的利益；鼓励创新和技术发展，同时保护专利权人的合法权益。在先使用理论上包括除了进口之外的所有可以构成专利侵权的国内实施行为，而不仅限于制造和使用。先用权抗辩是否成立，与被控侵权人是否能提供充分的法院可采信的证据相关，即需要以高度盖然性的证据表明“善意”或技术来源合法，并已经实施或为实施做好“必要准备”，以及在“原有范围”内继续实施与专利权人相同或等同的技术方案。

(一)提出先用权抗辩主体的界定

只有先澄清被告的主体资格和技术来源的合法性，才有适用先用权抗辩的余地。在我国，虽然立法并未明确，但实践中关于先用权抗辩的适用前提，即 在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠

纷案件应用法律若干问题的解释》进一步将这一前提条件概述为“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持”。换言之，先用权抗辩的适用主

